

1500433-39.2021.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Denise Gomes Bezerra Mota

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/08/2022

... CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá

Foro de Guarujá

1ª Vara Criminal

Rua Silvio Daige, 280, Guarujá-SP - cep 11440-550

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500433-39.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500433-39.2021.8.26.0536

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2026533/2021 - 01º D.P. GUARUJA, 15942070 - 01º D.P. GUARUJA, 68/21/219 - 01º D.P. GUARUJA, 2026533 - 01º D.P. GUARUJA, 2026533 - 01º

D.P. GUARUJA, 68/21/219 - 01º D.P. GUARUJA

D.P. GUARUJA, 68/21/219 - 01º D.P. GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Beneficiado - Art. 28-A CPP:

ADRIANO LUCCAS DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Denise Gomes Bezerra Mota

Vistos.

Adriano Luccas dos Santos, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no crime do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, no dia 29 de janeiro de 2021, por volta das 09:04 horas, na Avenida Quatro, altura do nº 236, Morrinhos, nesta cidade e Comarca de Guarujá, durante a pandemia da Covid-19, em

ocasião de calamidade pública, trazia consigo e guardava, para o consumo de terceiros, drogas consistentes em trinta e oito porções de cocaína, consoante o auto de exibição e apreensão de fls.09/10, o auto de constatação preliminar de fls.13 e as fotografias de fls.11 e 12, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado (fls.84) e apresentou defesa prévia (fls. 94/96), que não foi acolhida e a denúncia foi recebida (fls. 103/104).

Foi juntado aos autos o laudo de exame químico toxicológico realizado nas drogas apreendidas (fls.81/83).

Celebrado acordo de não persecução penal (fls.132/134), o réu descumpriu o acordo (fls.158 e 169) e foi retomada a ação penal (fls.174/175).

Durante a instrução criminal, foram ouvidas duas testemunhas comuns (fls. 195). Foi decretada a revelia do réu nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal (fls.197). Foi declarada encerrada a instrução e pelas partes não foram requeridas diligências (fls. 197).

O representante do Ministério Público, nos debates, requereu a procedência da ação nos exatos termos da denúncia, argumentando que a autoria e a materialidade restaram provadas durante a instrução criminal (fls.197/201).

Nos debates, a defesa do réu requereu a improcedência da ação nos termos do artigo 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, em caso de entendimento diverso, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da atenuante da confissão espontânea, a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006, no patamar máximo, a fixação do regime inicial aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, e a concessão ao réu do direito de apelar em liberdade (fls. 207/215).

É o relatório.

Decido.

A ação é procedente.

Com efeito, a materialidade do delito está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 06/08, pelo auto de exibição e apreensão de fls.09/10, pelas fotografias de fls.11/12, pelo auto de constatação preliminar de fls.13, pelo laudo de exame químico toxicológico de fls.81/83, bem como pela prova oral coligida nos autos. A autoria do réu também restou incontroversa pelas provas produzidas durante a instrução criminal.

Na fase policial, o réu exerceu o seu direito de permanecer em silêncio (fls.04).

Na audiência de instrução e julgamento realizada no dia 15 de junho de 2022, o réu deixou de ser ouvido ante a decretação da sua revelia (fls.197).

Contudo, ouvido em juízo, na audiência realizada no dia 06 de maio de 2021 (referente à celebração de acordo de não persecução penal), o réu confessou a prática do tráfico ilícito de entorpecentes (fls.136).

E a confissão do réu, como seria de rigor, restou corroborada pelas provas produzidas nos autos, que demonstraram a autoria delitiva e não foi apresentada situação a excluir o crime ou isentá-lo de pena.

Senão vejamos.

O policial militar Danilo Robson Soares da Silva, no seu depoimento judicial, disse que estavam em patrulhamento pelo bairro quando avistaram dois indivíduos em um ponto de venda de entorpecentes. Um dos indivíduos estava de bicicleta, segurando uma sacola, e o outro estava a pé. Eles estavam conversando. No momento em que encostaram com a viatura para realizar a abordagem, o indivíduo que estava de bicicleta se evadiu com a sacola na mão e o outro indivíduo correu em direção contrária. Acompanharam o indivíduo que estava de bicicleta e conseguiram abordá-lo. Neste momento, ele dispensou a sacola que carregava. Em busca pessoal, encontraram dinheiro em notas trocadas. Na sacola dispensada pelo réu, localizaram os entorpecentes. Indagado, o réu confessou a traficância, disse que estava vendendo os entorpecentes, pois passava por dificuldades. Afirmou que passou a noite no local e pegou "a carga de entorpecentes para revender ao longo do dia". Não se recorda da quantidade de entorpecentes encontrada na sacola, mas eram pedras de crack e cocaína. O dinheiro foi localizado no bolso do réu e estava em notas trocadas, eram mais de R\$200,00. Não conhecia o réu anteriormente. O réu disse que

estava desempregado e que recebia auxílio do Governo Federal. O outro indivíduo não foi abordado, pois fugiu em direção contrária. O local estava vazio no momento da abordagem, pois não costuma ficar cheio de usuários. A sacola foi localizada a cerca de cinco metros do réu, “no chão da via” (fls.202).

Rodrigo de Lima Rosa, policial militar, em juízo, narrou que na data dos fatos realizavam patrulhamento pela região e visualizaram o réu de bicicleta junto com outro indivíduo em local conhecido pela venda de drogas. O réu, que estava com uma sacola, esboçou uma reação estranha ao avistar a viatura. Então, acompanharam o réu e, ao se aproximarem para realizar a abordagem, ele dispensou a sacola. Pegaram a sacola de imediato e realizaram a abordagem do réu. Indagado, o réu confessou a traficância, disse que estava vendendo as drogas no local. Com o réu foram localizados um celular, maconha, e dinheiro em notas trocadas. O dinheiro estava com o réu. Não se recorda de detalhes dos fatos devido ao longo tempo decorrido. Não conhecia o réu anteriormente. O outro indivíduo que estava no local conseguiu fugir. A sacola dispensada estava a cerca de cinco a dez metros de distância do réu, mas foi imediatamente encontrada. Recorda-se apenas que com o réu foi localizado um celular. O réu aparentava estar cansado e afirmou que tinha passado a noite no local (fls. 202).

Ressalte-se que os depoimentos dos policiais merecem total credibilidade, pois não se pode presumir a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de delito, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial. Ademais, não restou comprovada qualquer razão concreta de suspeição.

A propósito, vem decidindo o Colendo Superior Tribunal de Justiça que:

"[...] os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, [...]".(STJ, HC 496335 / SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, j. 02/04/2019, Dje 08/04/2019).

"[...] O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova [...]" (STJ, HC 471082 / SP, Rel. Ministro Felix Fischer, j. 23/10/2018, Dje. 30/10/2018).

Ora, diante dos depoimentos dos policiais, da prova material apreendida e da confissão do réu, sem dúvida o réu trazia consigo e guardava os entorpecentes apreendidos e os entorpecentes eram destinados para o consumo de terceiros.

Tem-se que diante do contexto fático em que ocorreram os fatos, do teor dos depoimentos dos policiais, que narraram de forma segura e harmônica a conduta do réu, e diante da quantidade de entorpecentes encontrados com o réu, restou comprovada a conduta típica do réu narrada na inicial acusatória.

Portanto, diante das provas produzidas, a autoria do delito é indiscutível. É certo que o réu trazia consigo e guardava os entorpecentes e os entorpecentes eram destinados para o consumo de terceiros, ante a conduta do réu narrada pelos policiais, destacando-se que o artigo 33 da Lei nº 11.343/06 descreve condutas variadas, podendo ficar configurado o delito de tráfico de drogas ainda que o agente não tenha sido surpreendido praticando atos de comércio, como no presente caso.

Por fim, o crime de tráfico imputado ao réu restou consumado, restando evidenciado que os entorpecentes apreendidos com o réu eram destinados ao consumo de terceiros. Definida a conduta do réu, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, considerando os critérios do artigo 59 do Código Penal, bem como o disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, fixo a pena base no mínimo legal: 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Deixo de proceder a outros aumentos, tendo em vista que o réu agiu com dolo normal à espécie e as circunstâncias e consequências do delito não extrapolaram os limites inerentes ao próprio tipo penal.

Na segunda fase, destaco que a atenuante da confissão não pode levar a pena-base a quem do mínimo legal.

Ainda na segunda fase, deixo de reconhecer a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. No caso dos autos verifica-se que o estado de calamidade, em vigência desde o dia 20 de março após a publicação do Decreto Legislativo nº 6/2020, em razão da pandemia do Covid-19, em nada contribuiu ou facilitou a execução do delito. Para a configuração da agravante, deve, pois, existir nexo entre a situação vivenciada no período de calamidade pública e o crime cometido, sob pena de se caracterizar responsabilidade penal objetiva. E, no caso dos autos, não restou comprovada a presença de qualquer facilidade para o cometimento do delito decorrente da situação de calamidade.

Na terceira fase, verifico que o acusado preenche os requisitos legais previstos no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, pois não possui antecedentes criminais e não existem indícios de que integra organização criminosa. Assim, preenchidos os requisitos legais, considerando a quantidade dos entorpecentes (11,5 gramas de cocaína - fls.81/83), aplico a causa de diminuição e reduzo a reprimenda em 2/3, perfazendo o total de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Fixo o valor do dia multa em seu patamar mínimo, nos termos do art. 49, § 1º, do Código Penal, sendo que o valor do dia multa deverá ser objeto de correção monetária, na forma do art. 49, § 2º, do Código Penal.

Em relação ao regime prisional, considerando que o pleno do STF decidiu que "O chamado tráfico privilegiado, previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas) não deve ser considerado crime de natureza hedionda." (HC 118533, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 23/06/2016), que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC nº 111.840/ES, afastou a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados, devendo-se observar, para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena, o disposto no artigo 33, c.c. o artigo 59, ambos do Código Penal, modifico entendimento anterior e passo a entender que o crime de tráfico de drogas privilegiado não é crime equiparado a hediondo, de forma que o regime será fixado de acordo com o disposto nos artigos 33 e 59 do Código Penal.

Neste sentido a jurisprudência:

"HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO:

INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos. 2. O tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa. 3. Há evidente constrangimento ilegal ao se estipular ao tráfico de entorpecentes privilegiado os rigores da Lei n. 8.072/90. 4. Ordem concedida" (Pleno, HC nº 118.533, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 23/06/2016 grifos da reprodução).

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. AFASTAMENTO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ACUSADO SEM OCUPAÇÃO LÍCITA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RESTABELECIMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA ESTABELECIDNA SENTENÇA. REGIME PRISIONAL FECHADO COM BASE NA HEDIONDEZ E NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME ABERTO DEFERIDO, POIS PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. - O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. - Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços),

a depender das circunstâncias do caso concreto. - Não há como manter a fundamentação utilizada pelo Tribunal de origem, que afastou a figura do tráfico privilegiado sob a tese de que o paciente dedica-se às atividades criminosas pelo fato de não exercer atividade lícita, pois estava desempregado à época dos fatos. Ademais, a quantidade da droga apreendida - 2,71g de cocaína -, apesar de nociva, não foi tão elevada a ponto de indicar, juntamente com as circunstâncias em que ocorreu o delito, a dedicação do acusado às atividades criminosas. - O STF, ao julgar o HC n. 111.840/ES, por maioria, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei 8.072/1990, com a redação dada pela Lei n. 11.464/2007, afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados. - Hipótese em que o paciente é primário, condenado à pena não superior a 4 anos de reclusão, com análise favorável das circunstâncias judiciais, razão pela qual faz jus ao regime inicial aberto, conforme art. 33, § 2º, alínea c, do CP. - Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para restabelecer a sentença que fixou as penas em 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 221 dias-multa e modificar o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto. (HC 336.143/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 16/08/2016). E sendo assim, analisando os autos, tendo sido a reprimenda final estabelecida em patamar inferior a 4 anos de reclusão, fixo o regime aberto para o cumprimento da pena.

Cumprir destacar que, apesar da Resolução nº 5 editada pelo Senado Federal, que suspendeu a expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" presente no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, não seria o caso de substituição da pena, pois não se mostra medida suficiente e adequada ao presente caso.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública move contra Adriano Luccas dos Santos para CONDENÁ-LO à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por violação ao artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

O acusado poderá apelar em liberdade.

Após o trânsito em julgado, nos termos da Lei nº 11.343/06, oficie-se à Autoridade Policial determinando-se a destruição das substâncias entorpecentes reservadas como contraprova.

Após o trânsito em julgado, determino o perdimento do telefone celular e do dinheiro (R\$ 208,00) apreendidos, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, tendo em vista que as provas produzidas nos autos demonstraram se tratar de produto de tráfico ilícito de entorpecente. Providencie-se o necessário.

No que tange às custas processuais, diante da nomeação de Defensor Público Estadual, tem-se que foi deferida tacitamente assistência judiciária gratuita ao réu. E sendo assim, fica suspenso o pagamento das custas, nos termos do disposto no artigo 12 da Lei 1.060/50.

Publique-se, intime-se e comunique-se.

Guaruja, 06 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA